

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 629/2551

พนักงานอัยการ จังหวัดสงขลา

โจทก์

นายสมเกียรติ ธีรพิสุทธิ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 272 (1)

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109, มาตรา 110

เมื่อเปรียบเทียบรูปและคำของเครื่องหมายในภาพถ่ายแผ่นป้ายหน้าร้านที่เกิดเหตุกับเครื่องหมายบริการของผู้เสียหายจะเห็นว่าแผ่นป้ายดังกล่าวอยู่ในแนวตั้ง มีสีเหลืองและมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ (โรมัน) สีแดงเรียงจากด้านบนมาด้านล่างว่า N PHOTO EXPRESS โดยอักษร N ทำเป็นตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายอักษรประดิษฐ์ตัว K ของผู้เสียหาย ส่วนคำว่า EXPRESS ก็มีลักษณะของการวางตัวอักษร ลวดลาย และสีก็คล้ายคลึงกับเครื่องหมายบริการคำว่า K KODAK EXPRESS ของผู้เสียหาย แม้คำว่า PHOTO ของเครื่องหมายในแผ่นป้ายหน้าร้านจะไม่คล้ายคำว่า KODAK ของผู้เสียหาย และผู้เสียหายปฏิเสธสิทธิว่าจะไม่ใช่คำว่า EXPRESS แต่เพียงผู้เดียว แต่การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายต้องพิจารณาป้ายบริการทั้งหมดประกอบกัน มิใช่พิจารณาจากตัวอักษรหรือคำใดคำหนึ่ง จึงเห็นว่าเครื่องหมายบริการในแผ่นป้ายหน้าร้านที่เกิดเหตุมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้เสียหายดังกล่าว เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายของผู้เสียหาย

เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่าจำเลย
 ไม่มีความผิดฐานเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม และโจทก์มิได้
 บรรยายฟ้องว่าจำเลยให้บริการหรือเสนอบริการเลียนแบบเครื่องหมายบริการของผู้

เสียหาย จึงไม่ต้องปรับบทว่าจำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 และโจทก์ก็มีได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยเอาชื่อ รูป รอย ประติษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้ห่อหุ้มเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นการค้าของผู้เสียหาย อันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) ด้วย จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานนี้ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พิจารณา แต่เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวในฐานเลียนเครื่องหมายบริการของผู้เสียหาย อันเป็นความผิดกฎหมายบทเดียว คือ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108, 109, 110, 115 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 272 (1), 275 และสิ่งริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109, 110 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109, 110 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ปรับจำเลย

20,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
ข้อหาอื่นและคำขอให้รับของกลางให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า จำเลยเลียนเครื่องหมายบริการของโจทก์หรือไม่ ซึ่งในปัญหานี้จำเลยอุทธรณ์ว่า เครื่องหมายบริการ N PHOTO EXPRESS ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านที่เกิดเหตุ ไม่มีส่วนคล้ายคำว่า KODAK ของผู้เสียหาย ส่วนคำว่า EXPRESS ผู้เสียหายก็ได้ปฏิเสธสิทธิไว้ว่าไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในคำนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบรูปและคำของเครื่องหมายในภาพถ่ายแผ่นป้ายหน้าร้านที่เกิดเหตุ กับ เครื่องหมายบริการของผู้เสียหายจะเห็นว่าแผ่นป้ายดังกล่าวอยู่ในแนวตั้ง มีสีเหลือง และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ (โรมัน) สีแดงเรียงจากด้านบนมาด้านล่างว่า N PHOTO EXPRESS โดยอักษร N ทำเป็นตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นซึ่งมีลักษณะคล้าย อักษรประดิษฐ์ตัว K ของผู้เสียหาย ส่วนคำว่า EXPRESS ก็มีลักษณะของตัวอักษร ที่เอนและปรูโปรงคล้ายของผู้เสียหายเช่นกัน นอกจากนี้ลักษณะของการวางตัว อักษร ลวดลาย และสีก็คล้ายคลึงกับเครื่องหมายบริการคำว่า K KODAK EXPRESS ของผู้เสียหาย แม้คำว่า PHOTO ของเครื่องหมายในแผ่นป้ายหน้าร้าน จะไม่คล้ายคำว่า KODAK ของผู้เสียหาย และผู้เสียหายปฏิเสธสิทธิว่าจะไม่ใช่คำว่า EXPRESS แต่เพียงผู้เดียว แต่การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายต้องพิจารณาป้าย บริการทั้งหมดประกอบกัน มิใช่พิจารณาจากตัวอักษรหรือคำใดคำหนึ่ง จึงเห็นว่า เครื่องหมายบริการในแผ่นป้ายหน้าร้านที่เกิดเหตุมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับ เครื่องหมายบริการของผู้เสียหายดังกล่าว เป็นการเลียนเครื่องหมายบริการของผู้เสียหายตามฟ้อง อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ประการต่อมาว่า จำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการกระทำ ผิดเพราะนางสาวชุตติมาพยานจำเลยเบิกความว่าร้านนครศิลป์ คัลเลอร์แล็บ ที่เกิด เหตุเป็นสาขาหนึ่งของห้างหุ้นส่วนจำกัดรังสีบริภัณฑ์ ตามหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคลของห้างและใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น เห็นว่า โจทก์มีนางสาว เกติรัตน์มาเบิกความเป็นพยานโจทก์ยืนยันว่าพยานเป็นพนักงานขายสินค้าของ จำเลยในร้านที่เกิดเหตุที่มีจำเลยเป็นเจ้าของร้าน ซึ่งจำเลยมิได้นำสืบหักล้างว่าคำเบิก ความดังกล่าวของนางสาวเกติรัตน์ไม่เป็นความจริง ส่วนที่จำเลยนำสืบนางสาวชุตติมา ก็ได้ความเพียงว่า ร้านที่เกิดเหตุเป็นสาขาของห้างหุ้นส่วนจำกัดรังสีบริภัณฑ์ที่มี นางสาวชุตติมาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเท่านั้น นางสาวชุตติมาไม่ได้ยืนยันปฏิเสธว่า นางสาวเกติรัตน์ไม่ใช่พนักงานของจำเลยและร้านที่เกิดเหตุไม่ใช่ของจำเลย พยาน หลักฐานที่จำเลยนำสืบมาจึงไม่อาจหักล้างน้ำหนักของพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของร้านนครศิลป์ คัลเลอร์แล็บ ที่เกิดเหตุ อุทธรณ์ ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109, 110 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) อันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย หลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109, 110 ซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นั้น เห็นว่า เมื่อศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่าจำเลยไม่มีความผิด ฐานเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม และโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยให้บริการหรือเสนอบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการเลียนเครื่องหมายบริการของ ผู้เสียหาย จึงไม่ต้องปรับบทว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 และโจทก์ก็มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลย เอาชื่อรูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือ

ทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้ห่อหุ้มเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นการค้าของผู้เสียหาย อันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) ด้วย จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานนี้ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษา แต่เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวในฐานเดียว คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109 จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง